

1500970-95.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de drogas - Recurso defensivo pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal ou a redução do patamar de aumento, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "j" do Código Penal e o abrandamento do regime prisional, observando-se, inclusive, o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins - SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500970-95.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500970-95.2021.8.26.0322

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danielly de Sousa

Juíza de Direito: Dra. MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por seu representante que oficia perante este juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA contra DANIELLY DE SOUZA, como incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal acusada de, no dia 07 de maio de 2021,

pela manhã, na Rua José Fava, 385 - Bairro Do Junqueira - Cep: 16403- 075, nesta Cidade e Comarca, em situação de calamidade pública, manter sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, no interior de sua residência, especificamente um revólver calibre 38 e 08 (oito) munições íntegras, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia (fls. 65/66), na data dos fatos, Policiais Civis dirigiram-se ao endereço acima, para cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n. 1500955-29.2021.8.26.0322. Após diligências, encontraram, no quarto da Denunciada, dentro do guarda-roupa, entre o piso e uma gaveta, uma bolsa na cor azul, contendo um revólver calibre 38 e 08 munições íntegras. Referidos fatos ensejaram a prisão em flagrante da Denunciada, libertada, posteriormente, em virtude do recolhimento da fiança arbitrada pela d. Autoridade Policial.

A acusada foi presa em flagrante delito e houve recolhimento de fiança, estando a averiguada obrigada a cumprir o disposto nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, comparecendo ao Juízo competente ou à Delegacia de Polícia todas as vezes que for chamada, bem como não podendo se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência sem comunicar às autoridades o lugar onde será encontrada, sob pena de ser considerada quebrada a fiança.

O despacho de fls. 44 deferiu o pedido de gratuidade à acusada.

O Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, pois não houve confissão. Também deixou de oferecer sursis processual, pois a Denunciada responde a processo criminal (0001568-26.2021.8.26.0322 - fls. 59). Por fim, deixou de propor transação penal, pois o crime acima não se trata de infração de menor potencial ofensivo.

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2.021 (fls. 67).

A defesa da acusada peticionou nos autos (fls. 68/70), na qual se insurgiu contra a ausência de proposta de acordo de não persecução penal em favor da Ré.

O Ministério Público se manifestou às fls. 74/75, argumentando que a Requerida não preenche os requisitos legais para o oferecimento da citada benesse, prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

A decisão de fls. 82 indeferiu o pedido da defesa.

A ré Danielly de Souza foi citada e intimada (fls. 83).

O Ministério Público ofereceu promoção de arquivamento dos autos quanto a Maicon Anderson de Jesus Camargo, com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal.

O feito foi arquivado em relação ao averiguado MAICON ANDERSON DE JESUS CAMARGO, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal (fls. 90).

A acusada apresentou resposta à acusação (fls. 92/95).

Descartada hipótese de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 100/101).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas da acusação, sendo, ao final, a ré interrogada.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em fls. 141/146, pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia.

A Defesa, por sua vez (fls. 150/154), clamou pela absolvição, por ausência de provas ou pelo reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, b, do Código Penal, além da aplicação do artigo 44 do Código Penal ou que o início de regime de cumprimento da pena seja o aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

Maria Célia de Souza, ouvida como informante, por ser mãe da ré afirmou que os policiais foram cumprir mandado judicial e encontram armas e munições. Não sabia da existência da arma, que estava nos pertences da ré. O Maicon era ex-namorado da ré. Alguns dias anteriores, o Maicon foi pego com uma arma de fogo, com um vídeo que ele estava disparando-a, que seria a mesma que foi pega em sua casa. O ex-namorado tinha acesso direto à residência, por saber onde se encontrava a chave. Ele posou na casa de domingo para segunda e de segunda para terça. Afirma que o Maicon entrou com uma mochila preta dias antes, pois estava na sala e o viu. A ré nunca teve envolvimento com nada, logo acredita que a arma era do Maicon. Não perguntou o que estava na mochila.

A policial civil Andressa Amado dos Santos, testemunha da acusação, afirmou que cumpriu o mandado na casa da ré, por estar lotada na delegacia de Guaíçara. Ao entrarem no imóvel, mais precisamente no guarda-roupa, ao retirar algumas gavetas, foi encontrada a arma. Não sabe falar sobre acerca da investigação, porque estava lotada em Guaíçara na época dos fatos. Deu apenas apoio ao cumprimento do mandado de busca. A arma foi encontrada nos aposentos da ré. Após a localização da arma de fogo, a genitora da ré indicou que ela estaria trabalhando e foi solicitada a diligência da equipe policial para encaminhar a ré para a delegacia para justificativa. Nada foi questionado à ré, apenas encaminhando à delegacia. Após, retornou para a sua unidade.

O policial civil Ederval Emerson de Souza Perin, testemunha da acusação, afirmou que cumpriu o mandado na casa da ré. O mandado foi cumprido por alguns disparos de arma de fogo que estavam ocorrendo na avenida. Um dos vizinhos afirmou que seria o namorado dela da época, Maicon, que fazia os disparos. Ao cumprirem o mandado, acharam uma mochila preta com o revólver desmuniado e oito projéteis intactos. A princípio, a ré negou a existência da arma em sua casa. Ainda, a ré negou que seria namorada de Maicon. Após afirmarem que o Maicon estava preso, ela confirmou que ele frequentava sua casa, inclusive dormindo de domingo até terça, e afirmou que a arma seria dele. Não se recorda com exatidão, mas parece que havia uma foto da ré com a arma. Recorda-se de haver uma foto da ré com a arma na cintura. As informações eram que o namorado dela escondia a arma ali, mas ela negou o relacionamento. O revólver achado na casa da ré era um preto, oxidado. Nada indica que a arma da foto era a mesma da encontrada. A arma encontrada foi a que teria efetuado os disparos no Centro da cidade. Acredita que as duas armas passaram na mão da ré. Para ele, não foi justificada a existência da arma ou da foto.

A ré Danielly de Souza, em juízo, disse que está gestante, trabalha na JBS e ganha R\$2.200,00. Estava trabalhando no dia dos fatos e os policiais foram lhe buscar. Alegou que não sabia o que estava acontecendo e os policiais informaram da arma, que negou ter conhecimento. Foi até a delegacia e foi apresentada a arma. Negou que a arma fosse sua. Acredita que a arma de fogo era do Maicon, porque ele é o único que frequentava a sua casa, além de sua família. Ele fez vídeos atirando com essa arma. Na época, não namorava o Maicon, mas tinham um bom relacionamento e ele tinha acesso à sua casa. Os disparos dos vídeos foram realizados no final de semana anterior aos fatos. O Maicon dormiu na sua casa de domingo até terça. A mochila que foi encontrada com a arma era uma pequena do Boticário. Geralmente ele chegava na sua casa com uma mochila maior, para levar a roupa para dormir, mas nunca abriu a mochila dele para ver. O Maicon tinha acesso a todos os cômodos da casa. A arma apreendida não é sua. Sobre as fotos juntadas aos autos, está com uma arma no punho, mas não é a que foi apreendida. Sobre a outra arma, que tem uma foto em sua cintura, não é uma arma verdadeira, mas de brinquedo, porque comprou para uma fantasia. Explicou aos dois policiais que lhe abordaram a sua versão, inclusive em frente a um supervisor do trabalho. Contou toda narrativa inclusive para a policial Andressa, que a acompanhou na delegacia, até mesmo no banheiro.

Encerrada a exposição da prova oral fornecida pelas testemunhas e pela ré, convém salientar que não há qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Com efeito, a materialidade do crime encontra-se devidamente provada pelo auto de

prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo relatório final de fls. 46/48, pelo laudo pericial de fls. 130/137, bem como prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria dos fatos também é certa e recai sobre a acusada, diante da prova oral colhida em sede de instrução.

O delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 restou plenamente configurado. A conduta típica de possuir e manter sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido é inconteste, vez que a ré a tinha ao seu alcance e lhe era possível pronta utilização.

O laudo pericial acostado aos autos (fls.130/137) atestou a potencialidade lesiva da arma e a eficiência das munições que a acompanhavam.

Destaque-se que a posse ilegal de arma de fogo constitui crime formal e de perigo presumido ou abstrato, não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco. Para a consumação, basta a realização de qualquer das ações descritas no tipo penal (no caso, possuir e manter sob sua guarda), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante qualquer fato posterior.

Nesse sentido:

"[...] 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que "os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato" (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux) [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1122678 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).

"Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial" (STJ, HC 366.292/SE, Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2017).

À hipótese não incide o princípio da insignificância, pois, na linha da inteligência do Superior Tribunal de Justiça "Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo penal. Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo e munição, notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção eficiente. (...) (STJ, REsp nº 1.699.710/MS, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, J. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Demonstrado à sociedade que a agente tinha a posse irregular de arma e munições, adequada a modelagem de sua conduta ao artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Por sua vez, a versão da ré não merece respaldo, pois, ainda que a arma não fosse de sua propriedade, mas de seu ex-namorado, com efeito a arma estava em sua posse, sendo encontrada escondida dentro de seus pertences. Logo, não é crível imaginar que a ré não soubesse da sua existência, como aponta sua defesa.

Por fim, a acusação pleiteia seja aplicada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, a qual, contudo, não encontra guarida no caso em apreço.

Insta salientar que o estado de calamidade pública decretada em virtude da pandemia não facilitou a execução do crime: não consta que a região estava com policiamento restrito, não há vítima direta cuja vigilância estivesse reduzida em razão da pandemia.

Situação distinta, por exemplo, seria a do agente que promete cura da doença valendo-se de ardil, aproveitando-se da situação criada pelo estado de calamidade pública, ou que adentra estabelecimento comercial fechado em razão da pandemia, com menor vigilância da vítima sobre os bens que ali existiam.

Não é possível dizer que o agente se valeu das “facilidades” provocadas pela pandemia para a prática do crime em questão. Portanto, incabível o aumento na fração aplicada em segunda fase por esta razão.

Na lição da doutrina: “Por ocasião de calamidade pública: O CP manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-o em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc.”. (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 271). (Grifei)

Nesse sentido, a reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de drogas - Recurso defensivo pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal ou a redução do patamar de aumento, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “j” do Código Penal e o abrandamento do regime prisional, observando-se, inclusive, o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade do delito bem comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao decreto condenatório - Pena ajustada - Exacerbação da pena base bem justificada - Consideração da personalidade do agente e da natureza das drogas apreendidas - Redução de 1/5 de aumento - Réu foi beneficiado com a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea - Preponderância da circunstância agravante da reincidência sobre todas as atenuantes - Inteligência do art. 67 do CP - Afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “j” do CP - Não demonstrado que o agente se aproveitou da situação de calamidade pública para cometer o delito - Inaplicabilidade do redutor Regime prisional fixado com critério - Inaplicabilidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - A competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções Parcial provimento. (TJSP, Apelação nº 1510439-93.2020.8.26.0228, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. em 22.10.2020).

Embora tenho o Estado Brasileiro decretado estado de calamidade pública em data anterior aos fatos narrados na inicial, em razão da pandemia da doença COVID-19, deve-se apontar que a natureza de tal calamidade em nada facilita a execução do crime em tela. Ao contrário, tratando-se de doença altamente contagiosa transmitida por via aérea, é de se esperar que uma quantidade menor de pessoas esteja disposta a sair às ruas para adquirir drogas. Por outro lado, a natureza do crime praticado pelo réu em nada agrava as consequências de tal calamidade. Evidente que as circunstâncias previstas na alínea “j” do inciso II do artigo 61 do Código Penal devem ter relação direta com o crime praticado para que possam ser reconhecidas. É o caso, por exemplo, de crime de furto cometido após enchente, quando as casas se encontram abandonadas por seus proprietários, ou de crime de tráfico de pessoas durante migração forçada por desastres naturais, onde claramente se aproveita o autor dos delitos da situação de calamidade para cometer o crime. Não é o caso dos autos. O acusado não obteve qualquer vantagem ou facilidade na execução do crime em razão da pandemia que ora assola o país, não sendo assim possível reconhecer-se, aqui, a agravante aventada. (TJSP, apelação nº 1509934-05.2020.8.26.0228, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. em 14.10.2020).

Dessa forma não é possível dizer que a acusada se valeu das “facilidades” provocadas pela pandemia para a prática do crime em questão. Portanto, incabível a aplicação de referida agravante.

Constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade dos fatos, passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Ademais, também não cabe a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea b, como solicita a defesa. Isso porque não há nada nos autos a demonstrar que a ré procurou evitar ou minorar as consequências do delito ou que tenha reparado o dano. Ressalto que a arma foi encontrada pelos policiais no cumprimento de mandado de busca e apreensão; ou seja, em nenhum momento a ré entregou a arma que estava em sua posse por espontânea vontade.

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito aos tipos penais. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: não há antecedentes (fls. 59/60 e 79/80).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social da ré. Portanto, indevido o aumento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade da ré. Portanto, indevido o aumento da pena.

E) Motivos do crime: O motivo é ínsito aos tipos penais.

F) Circunstâncias do crime: são normais às espécies.

G) Consequências do crime: Não há razão também o incremento da pena.

H) Comportamento da vítima: trata-se de crime vago.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar fixado, ou seja, a pena em 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

Terceira etapa

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Aberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Cabível, afinal, a ré foi condenada a pena inferior a 4 anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), não é reincidente em crime doloso (artigo 44, inciso II, do Código Penal) e as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição seja suficiente.

Portanto, em atenção ao fato de a pena privativa de liberdade ser igual a 1 (um) ano (artigo 44, § 2º, do Código Penal), aplico, em substituição à pena privativa de liberdade, a pena de prestação pecuniária, em um salário mínimo, a ser revertida a entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal.

Valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar DANIELLY DE SOUSA à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da conduta descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, substituo-a pela pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser revertida a entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal.

Havendo descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, voltará a incidir a pena privativa de liberdade inicialmente fixada.

Considerando a quantidade de pena, o regime inicial e as substituições operadas, e ausentes, a princípio, os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, concedo a ré o benefício de recorrer em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, ressalto ser beneficiária da justiça gratuita.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Lins, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA